

0005999-02.2015.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005999-02.2015.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005999-02.2015.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

Diego de Oliveira Assunção e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Marcio Antonio Siqueira dos Santos e Diego de Oliveira Assunção, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, porque no dia 6 de março de 2015, à noite, no Bar da Andrea, Rua Cafelândia, 947, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo uma carteira e R\$550,00 da(s) vítima(s) Juyllames Girmino dos Santos.

Auto de reconhecimento fotográfico nas fls. 20/25.

A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2021 (fls. 221/222).

Os réus foram citados (fls. 252 e 255) e foi(ram) apresentada(s) a(s) defesa(s) preliminar(es) (fls. 259/261 e). Ela(s) fo(ram) rejeitada(s) e designou-se audiência de instrução (fl. 262). Durante a instrução foram ouvidas testemunha(s) e vítima(s), e, ainda, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações oralmente ao final da audiência.

É o relatório. Decido.

Os réus Marcio Antonio Siqueira dos Santos e Diego de Oliveira Assunção foram denunciados pela Promotoria de Justiça por roubo qualificado pelo concurso de pessoas porque em 6 de março de 2015, à noite, no Bar da Andrea, Rua Cafelândia, 947, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo uma carteira e R\$550,00 da(s) vítima(s) Juyllames Girmino dos Santos.

De acordo com a denúncia, a vítima estava no balcão do bar de sua esposa, havia quinze clientes no local. Os réus entraram, munidos de arma de fogo e mascarados, anunciaram o roubo e mandaram que as vítimas ficassem de costas para si, voltadas para a parede, ao que um dos réus desferiu um chute nas nádegas da vítima. A testemunha Joselma visualizou o rosto do réu Márcio, que estava armado, porque a máscara dele caiu durante o assalto. Ela também reconheceu Diego por uma tatuagem no pescoço e pela voz.

Os réus foram interrogados em juízo e negaram a prática do crime. Segundo eles, não teriam relação alguma com o caso.

Apenas a negativa do réu Márcio, entretanto, merece acolhida, como salientou o Ministério Público em alegações finais.

Em solo policial a vítima Juylames declarou que na data do fato estava iniciando as atividades no bar de sua esposa e havia em torno de quinze clientes no estabelecimento. Dois homens entraram, usando máscaras, um deles estava armado e o outro tinha uma tatuagem no pescoço. Não teria como reconhecê-los porque não viu os rostos nem outras características e ainda não conhecia as pessoas daquele bairro. Ouviu comentários de que Diego seria um dos autores, mas não o conhecia. Os assaltantes mandaram que os presentes ficassem de costas para eles, de frente para a parede e alguém chutou o depoente. Eles revistaram os presentes, do depoente levaram carteira, dinheiro e celular. Os clientes também foram roubados, mas não quiseram ir à delegacia.

A vítima Joselma, de seu turno, relatou nas duas fases da persecução que na data do fato estava no "Bar da Andrea", assim como outras vinte pessoas. Dois homens mascarados, um deles armado, chegaram de motocicleta, entraram no bar e baixaram a porta, depois mandaram que os presentes se aproximassem da parede, de costas para os assaltantes. A depoente demorou um pouco para obedecer, por isso teve tempo de ver o rosto do homem armado quando a máscara dele caiu. Levou um tapa por isso. Os assaltantes revistaram todos os presentes e pegaram suas carteiras e celulares, mas a depoente nada tinha consigo. Ouviu um dos assaltantes dizer o nome de um dos clientes presentes, sugerindo que o conhecia. Não viu o rosto do segundo assaltante, mas viu uma tatuagem grande no pescoço dele e ouviu sua voz. Depois do fato surgiram comentários de que Diego, vizinho da depoente, seria autor do roubo no bar, inclusive teria sido visto no local, de motocicleta, com outro homem. A depoente então lembrou que Diego também tinha uma tatuagem no pescoço e percebeu que a voz que ouvira do assaltante era parecida com a dele. Diego tinha uma má reputação no bairro, por supostamente agredir a genitora e ser usuário de drogas, depois do fato ele não foi visto mais nas imediações.

A vítima Joselma já havia reconhecido os réus na fase policial por fotografia. Na ocasião, segundo verifício dos autos (fls. 20/21), não foi observada a prescrição do artigo 226 do CPP, ou seja as imagens dos réus foram apresentadas isoladamente à vítima. Esse procedimento atualmente é rechaçado pela jurisprudência do STJ, que nega valor probante ao reconhecimento resultante.

Ocorre que, no caso do réu Diego, o reconhecimento pautou-se pelo sinal característico, tatuagem, pelo porte físico e pela voz dele, pois a vítima não viu seu rosto. Em juízo o reconhecimento foi realizado, por videoconferência, observando-se os parâmetros legais, e a vítima reconheceu o réu entre outros homens, inclusive identificou a voz dele.

Justamente ele foi reconhecido em juízo pela vítima, sem sombra de dúvidas.

Salientou ela que a toca dele caiu e que verificou a fisionomia dele; rosto e tatuagem. Também ressaltou que não haveria como não reconhecê-lo porque ele morava perto da casa dela e que o encontrou no dia seguinte ao assalto.

Quanto ao corréu Márcio, a vítima viu o rosto dele, mas não o reconheceu em juízo, por videoconferência. Ela confirmou que o reconheceu na fase policial, mas em juízo disse que ficou em dúvida para que fizesse o reconhecimento.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Registro que o dispositivo sob exame foi alterado pela Lei nº 13.964, de 2019, de forma que a majorante decorrente do emprego de arma de fogo foi deslocada para o

§2º-A e agora implica aumento fixo de 2/3 da pena. A inovação foi maléfica para os réus, por isso será aplicado o patamar previsto na lei vigente na época do fato, mas no dispositivo da sentença constará referência à capitulação atual do crime. Na primeira fase de aplicação da pena, entendo que deve ser levado em conta em desfavor do réu o fato de que empregou desnecessária violência contra as vítimas, depois de elas terem sido rendidas pela grave ameaça. A vítima Juylames levou um chute, ao passo que a vítima Joselma foi agredida com tapa. Considero, ainda, o fato de que os réus tomaram de assalto o bar inteiro, no qual havia quinze ou vinte clientes, revistaram todos e levaram pertences daqueles que os portavam. Os réus não foram denunciados pelas subtrações contra os outros clientes, nem se sabe ao certo o que foi que eles conseguiram apanhar naquela ocasião, mas a prova indica que foi promovido um verdadeiro "arrastão", um roubo massivo, existe desvalor acentuado na conduta, que deve ser reprovado proporcionalmente pela pena. Fixo-a, portanto, acima do mínimo legal, em 5 anos de reclusão.

Ademais, o réu ostenta condenações anteriores, algumas delas caracterizam maus antecedentes. Ele respondeu aos autos 0025330 48 2007 (1ª Vara Criminal local), a condenação transitou em julgado em 23/08/2012 (fls. 280/281) e a pena respectiva foi extinta em junho de 2014 (fl. 235); nos autos 0001235 97 2009, da 2ª Vara Criminal de Carapicuíba, o acórdão condenatório transitado em julgado em 15/09/2011 (fls. 282/283) – pena extinta em 08/2013 pelo indulto (fl. 235).

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte, essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes". Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO).

CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014). (...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Destarte, considerando tudo quanto exposto, fixo a pena-base acima do mínimo legal: 6 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena noto que está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado nos autos 0007246 04 2004, 1ª Vara Criminal local, acórdão transitou em julgado em 07/12/2009 (fls. 279/280) e a pena extinta pelo indulto em setembro de 2018 (fl. 235).

Em razão da reincidência, aumento a pena a ser cumprida por ele(s) em 1/3, adotando analogicamente o critério estabelecido pelo artigo 110 do Código Penal, perfazendo 8 anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena há as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Como o STJ no enunciado 443 de sua súmula rechaça o aumento superior ao mínimo fundamentado apenas no número de majorantes e no caso não há elementos ligados a essas circunstâncias que sejam especialmente dignos de reprovação, mantenho o aumento no patamar mínimo de 1/3.

A pena passa a 10 anos e 8 meses de reclusão.

O emprego de grave ameaça e violência, bem como a quantidade de pena aplicada, reincidência e antecedentes afastam o direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição econômico-financeira dos réus. Como no caso em tela não há dados concretos acerca dessa condição dos réus, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

a. Absolver o réu Marcio Antonio Siqueira dos Santos da acusação fundada na prática do crime do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e,

b. Condenar o réu Diego de Oliveira Assunção, ao cumprimento de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Tendo em vista que o réu Diego respondeu ao processo em liberdade e que não existem motivos para que seja decretada a prisão provisória deles nesse momento, a teor do artigo 312 do Código de Processo Civil, permito que permaneça nessa situação até o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA